

1500138-37.2022.8.26.0416

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUÍS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA

Comarca: Panorama

Foro: Foro de Panorama

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... para condenação quanto ao crime de tráfico; subsidiariamente, clamou pela desclassificação do delito de tráfico para o delito de uso, com aplicação de benefícios no tocante a pena. No tocante ao delito de associação para o tráfico, aduz a ausência de animus associativo entre os acusados.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Passo à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Panorama

Foro de Panorama

1ª Vara Judicial

Rua Manoel Fernandes da Cunha, nº 1308, Panorama - SP - cep 17980-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500138-37.2022.8.26.0416 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500138-37.2022.8.26.0416

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GRAZIELLY APARECIDA PEREIRA CARDOSO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUÍS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA

Vistos.

GRAZIELLY APARECIDA PEREIRA CARDOSO e RAFAEL DE SOUZA RODRIGUES estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal, isso porque, segundo a denúncia (fls. 179/183):

1. No dia 03 de março de 2022, por volta das 16h, na Vicinal SPV 16, Km 03 e na Rua Aurora Francisco de Camargo, nº 608, ambos endereços localizados nesta cidade e comarca de Panorama, RAFAEL DE SOUZA RODRIGUES e GRAZIELLY APARECIDA PEREIRA CARDOSO, guardavam no primeiro endereço, para fins de entrega a terceiros, massa líquida total de 8185 g (oito mil cento e oitenta e cinco gramas) de maconha (cf. auto de exibição e apreensão de f. 26-27 e laudo pericial de f. 31-35), bem como mantinham em depósito na residência do casal, localizada no segundo endereço, massa líquida total de 37,09 (trinta e sete gramas e nove centigramas) de maconha (cf. auto de exibição e apreensão de f. 26-27 e laudo pericial de f. 36-40), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização

e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

2. Além disso, em data anterior ao dia 03 de março de 2022, mas certamente até esta data, na cidade e comarca de Panorama, RAFAEL DE SOUZA RODRIGUES e GRAZIELLY APARECIDA PEREIRA CARDOSO associaram-se entre si para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Segundo consta dos autos, na data e locais acima descritos, RAFAEL DE SOUZA RODRIGUES e GRAZIELLY APARECIDA PEREIRA CARDOSO, se associaram, guardavam e mantinham em depósito as referidas drogas, com intuito de venda a outrem. Ocorreu que, policiais militares faziam patrulhamento de rotina, quando avistaram o veículo Space Fox, cor preta, placas CWQ5748 de Panorama, o qual era conduzido por RAFAEL e tinha GRAZIELLY como passageira.

Outrossim, tendo em vista que RAFAEL é conhecido dos meios policiais, bem como demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial, deliberaram por abordá-los e deram ordem de parada que foi prontamente atendida.

A seguir, realizaram revista pessoal nos DENUNCIADOS e no veículo, mas nada de ilícito foi localizado.

Ato contínuo, os policiais separaram o casal e os indagaram sobre o que faziam naquele local, sendo que GRAZIELLY acabou confessando que estavam chegando da cidade de Ouro Verde, porquanto foram negociar entorpecente, bem como relatou que a droga que pretendiam vender havia sido escondida em um canavial.

Após GRAZIELLY confessar os fatos, RAFAEL confirmou a versão de sua amásia e aceitou mostrar aos policiais o local em que a droga estava escondida.

A seguir, RAFAEL levou os policiais até um canavial localizado no Km 3 da Vicinal SPV 16, sentido Panorama-Ouro Verde, e apontou o local exato em que o entorpecente estava homiziado. Então, os policiais se depararam com um saco preto amarrado e no seu interior havia 9 tablets inteiros e 3 pela metade de maconha.

Na sequência os policiais e os DENUNCIADOS se dirigiram a residência do casal e lá se depararam com uma tia de RAFAEL, a qual autorizou as buscas no local.

Em revista no imóvel, os policiais lograram encontrar no quarto do casal, encima de uma estante, uma sacola plástica contendo uma porção de maconha.

Submetidos os entorpecentes a exame preliminar de constatação, verificou-se tratar-se ambos de maconha, a primeira com massa líquida total de 8185 g e a segunda com massa líquida total de 37,09 g.

A quantidade de drogas apreendidas, sua forma de acondicionamento, bem como as circunstâncias do flagrante, aliada a confissão dos DENUNCIADOS evidenciam a intenção de tráfico pelos DENUNCIADOS, em caráter associativo.

Os réus foram presos em flagrante (fls.01/02), sendo a prisão convertida em preventiva (termo de audiência de custódia fls. 82/86).

A denúncia foi recebida em 12/04/2022 (fls. 191/193).

Os réus foram citados e ofereceram resposta prévia à acusação (fls. 252/255 e fls. 267/279).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha (Felipe) e homologada a desistência da oitiva de uma testemunha (Maysa). Após, os réus foram interrogados.

A defesa da acusada Grazielly pugnou pela revogação da prisão preventiva, o que foi negado.

O Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia.

A Defesa de ambos os acusados, por seu turno, requereu prazo para apresentação de memoriais, o que foi concedido (termo de audiência fls. 300/302).

Memoriais de defesa da ré Grazielly às fls. 303/329. Aduziu, preliminarmente, a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa com base na quantidade de substância apreendida. No mérito, sustentou a negativa de autoria com relação ao crime de tráfico de drogas, salientando que os entorpecentes apreendidos eram para consumo próprio do companheiro da ré, e a insuficiência probatória para condenação; quanto ao crime de associação para o tráfico, alegou a ausência de dolo na conduta da acusada e a insuficiência probatória para condenação; pugnou pela absolvição da ré com base no princípio do in dubio pro reo; subsidiariamente, requereu a aplicação de benefícios no tocante à pena e o direito de apelar em liberdade.

Memoriais da defesa do réu Rafael às fls. 331/344. Requereu, preliminarmente, o trancamento da ação penal com base no constrangimento ilegal. No mérito, sustenta a

insuficiência e fragilidade probatória para condenação quanto ao crime de tráfico; subsidiariamente, clamou pela desclassificação do delito de tráfico para o delito de uso, com aplicação de benefícios no tocante a pena. No tocante ao delito de associação para o tráfico, aduz a ausência de animus associativo entre os acusados. Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Passo à análise das preliminares arguidas.

Inicialmente, reitero a rejeição da preliminar de inépcia da denúncia apresentada em sede de memoriais, porquanto, além de preenchidos os requisitos necessários para seu oferecimento, nos termos do artigo 41, do CPP-inclusive a justa causa que se sustenta na grande quantidade de entorpecentes, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 26/27-, o momento processual adequado para levantamento de tal tese encontra-se superado pela instrução probatória já finalizada, e pelos fundamentos constantes na decisão de fls. 284/286.

Não obstante, a defesa do acusado Rafael busca o reconhecimento do constrangimento ilegal na abordagem policial, que resultaria na pretensa ilegalidade das provas por derivação, o famoso princípio dos frutos da árvore envenenada, cuja origem é atribuída à jurisprudência norte-americana (The fruits of the poisonous tree), doutrina esta que defende que todas as provas decorrentes de prova ilícita são contaminadas por este vício.

Contudo, diferentemente da visão defensiva (e isso não importa em rejeição ao entendimento doutrinário, mas à análise fática e verificação de sua (in) aplicabilidade), têm-se das provas dos autos, como se verá à frente, que não houve qualquer agir ilícito por parte dos policiais militares, ou constrangimento ilegal na abordagem.

Isso porque, conforme relatado pelo policial militar ouvido em juízo e pelas demais provas colhidas durante a fase inquisitiva, a abordagem foi procedida mediante fundada suspeita pelo comportamento dos acusados e conhecimento prévio do envolvimento de um deles em delitos contra a saúde pública, sendo que obteve resultado, já que culminou no encontro dos entorpecentes e na instauração do processo com vistas a repelir a traficância.

Nesse sentido tem decidido o tribunal de justiça bandeirante:

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - Alegação de ilicitude das provas derivadas da busca pessoal, veicular e violação de domicílio- Inocorrência - Crime permanente - Circunstâncias que justificavam a atuação dos agentes da lei - Preliminar afastada - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade- Admissão pelo réu do porte das drogas, embora negado o tráfico - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - Condenação mantida - Pena correta - Réu multirreincidente - Fração de 1/5 proporcional à existência de duas anteriores condenações - Regime fechado mantido - Recurso desprovido (voto nº 46152). (TJSP; Apelação Criminal 0001190-43.2020.8.26.0407; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osvaldo Cruz - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 17/05/2022)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRELIMINARES - Ilicitude da prova não configurada.

Abordagem e busca pessoal realizadas pelos policiais. Diligência que não foi aleatória, mas lastreada em elementos concretos. Fundada suspeita evidenciada. Inteligência do artigo 244 do CPP. Estado de flagrância - Afronta ao princípio constitucional da não autoincriminação (direito ao silêncio). Inexistência - Nulidade por inobservância do artigo 212 do CPP. Questionamentos formulados pelas partes processuais. Ato solene que atingiu os fins previstos em lei.

Instrumentalidade das formas. Ausência de demonstração de prejuízo (pas nullité sans grief). Desacolhimento - Rejeição. MÉRITO - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada - Apreensão de razoável quantidade de droga (32 porções de cocaína, pesando 14,82 gramas), além de dinheiro -

Desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Descabimento - Condenação mantida. (...). (TJSP; Apelação Criminal 1500363-74.2021.8.26.0551; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/05/2022; Data de Registro: 16/05/2022)

Ademais, acerca do assunto, preleciona Guilherme Nucci:

Crimes permanentes são aqueles que se consomem com uma única conduta, mas o resultado tem a potencialidade de se arrastar por longo período, [...] O tráfico de entorpecentes é crime permanente, prescindindo, assim, da prévia expedição de mandado judicial. (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: RT, 2008. p. 601).

A abordagem, tanto no veículo como na residência, não foram procedidas de forma aleatória. O estado de flagrância já estava configurado, uma vez que os crimes relacionados ao tráfico de drogas são permanentes e plurissubsistentes, ou seja, exaurem-se com o simples ato de portar, guardar, ter em depósito, possuir, etc, a substância entorpecente que cause dependência física ou psíquica.

Assim, em caso de fundada suspeita da existência de droga na posse dos acusados ou nas dependências de residência, pode a diligência ser realizada, sem ferir preceito constitucional. Este é o entendimento firmado na jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO POR PESSOA NÃO RESIDENTE NO IMÓVEL. INGRESSO MOTIVADO POR FUNDADAS RAZÕES. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 2. Por importar violação de domicílio, o mandado de busca deve ser preciso e determinado, indicando o mais precisamente possível a casa a ser diligenciada, o nome do proprietário (ou morador), não sendo admissível o mandado genérico, sob pena de tornar inviável o controle sobre os atos do Estado contra o direito individual. 3. O tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica em sua propriedade, ainda que na modalidade de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Autorização por pessoa que chama a propriedade (usucapião) da chácara de sogra e é mãe da neta da acusada. Precedentes do STF e do STJ. 4. Neste caso, o contexto fático antecedente mostra riqueza de elementos indicativos da prática delituosa, de modo que não há como acolher o pleito de nulidade das provas obtidas por meio do ingresso dos policiais na residência dos recorrentes. Ad argumentandum tantum, ainda que se desconsidere a autorização de entrada, dada por pessoa não residente no imóvel (hóspede), as demais circunstâncias que envolvem a ocorrência fornecem elementos sobejantes para permitir, em princípio, a providência tomada pelos agentes policiais. 5. De qualquer forma, a moldura fática delineada no acórdão do TJPR não permite alcançar conclusão segura quanto à alegada irregularidade da busca realizada na residência dos recorrentes. Para verificar se o ingresso dos agentes policiais no domicílio foi devidamente autorizado ou se a busca domiciliar foi precedida de averiguação quanto aos fatos narrados na denúncia anônima seria necessária ampla dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 6. Recurso ordinário improvido. (STJ - RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 141.544 - PR (2021/0015947-4), Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julg. 15 de junho de 2021). (grifei)

Diante deste cenário, não há mácula ou ilicitude nas provas obtidas nos autos, porquanto, a abordagem pessoal dos réus em fundada suspeita não constitui nenhum dos modos de constrangimento elencados no CPP.

Deste modo, REJEITO as preliminares suscitadas.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Inicialmente, verifico que não há provas consistentes da prática delitiva do delito de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006). Isso porque,

conforme o conjunto probatório dos autos, não se observa a presença do animus associativo prévio entre os acusados, ou conjugação de esforços e união de suas condutas para a prática de atividades criminosas.

A doutrina e a jurisprudência entendem que a caracterização do crime de associação exige a prova de uma união organizada entre seus membros, o que se distingue da singela reunião dos agentes. Associação implica na convergência de vontades e harmonia de ações, que se completam num todo homogêneo e estruturado em divisão de tarefas, e que buscam, num sentido único, a viabilização do tráfico, de maneira reiterada ou não.

Nessa medida, tecidas as considerações acima, não restou comprovado o ânimo associativo estável e duradouro entre os réus para a prática da traficância, já que não se verifica uma clara divisão de tarefas e permanência na conduta dos réus.

Aliás, da prova oral se extrai que, apesar de unidos no mesmo intento, foi corroborado pelo Réu Rafael que Grazielly, apesar de ciente das demais condutas que caracterizam sua participação no tráfico, não tinha ciência do local onde estavam homiziadas as primeiras substâncias apreendidas, o que torna duvidosa a harmonia de ações.

Em casos análogos, assim decidiu o tribunal de justiça bandeirante:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. I – Preliminar. Provas obtidas por meios ilícitos. Suposta invasão domiciliar dos policiais militares. Inocorrência. Crime permanente. II. Mérito. Absolvição do tráfico. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório firme e seguro a demonstrar a destinação mercantil da droga. Valorização e validade das palavras dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados. Apreensão de objetos, drogas e perícia no celular de um dos réus. Condenação também da corré absolvida - necessidade. (...) Associação para o tráfico. Não se demonstrando que havia prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, para a prática do delito de tráfico de drogas, deve ser mantida a absolvição dos apelados em relação à imputação prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/06. III - Penas e regime prisional mantidos. Detração penal. Não incidência. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E PROVIDO, EM PARTE, O RECURSO MINISTERIAL. (TJSP; Apelação Criminal 1500879-33.2019.8.26.0594; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/06/2022; Data de Registro: 27/06/2022)(grifei)

Ação Penal. Tráfico de Drogas c.c. Associação ao Tráfico. Sentença condenatória. Recursos dos réus objetivando a absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas. Admissibilidade parcial. Crime de tráfico: Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos. Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório. Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, bem configurada. Crime de associação ao tráfico: Não demonstrado. Acervo probatório insuficiente para o desate condenatório. Inexistência nos autos de provas cabais do vínculo associativo duradouro entre os réus, sob os aspectos da estabilidade e permanência. Aplicação do princípio in dubio pro reo. (...) (TJSP; Apelação Criminal 1500179-08.2020.8.26.0599; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/06/2022; Data de Registro: 21/06/2022)(grifei)

Com efeito, dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Há de se registrar que uma condenação só pode se apoiar em provas cabais, robustas, desprezando-se os indícios e as presunções, que não ostentam as qualidades de segurança e fidúcia exigidas em um decreto condenatório. Ademais, como cediço, meras conclusões e conjecturas não servem para dar alento a uma condenação, tão-somente a prova certa e vigorosa.

Conforme preconiza o standard da “prova além da dúvida razoável” (beyond a reasonable doubt), o decreto condenatório criminal deve se basear em uma possibilidade bastante elevada da ocorrência do fato imputado – seja quanto à

materialidade, seja quanto à autoria.

Assim, sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo, o juízo deve proferir uma decisão que favoreça aquele que, a princípio, presumir-se-ia inocente.

Deste modo, pelo fato de nenhum elemento probatório coeso indicar que os réus efetivamente tenham previamente se ajustado para a prática do delito de tráfico de drogas, não exsurge a certeza necessária à condenação, face ao princípio constitucional do estado de inocência, do qual é corolário o princípio do in dubio pro reo.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 22/25), auto de exibição e apreensão (fls. 26/27 e fls. 41/44), laudos de constatação (fls. 31/35 e fls. 36/40) e laudos definitivos de fls. 185/187 e fls. 188/190, bem como pela prova oral produzida em juízo.

Os laudos definitivos de fls. 185/187 e fls. 188/190 atestaram a presença de tetraidrocanabinol (maconha), nas porções de 37,09 e 8.185,0 gramas de substância ilícita, totalizando 8,222kgs de maconha (pouco mais de oito quilos de maconha).

A autoria, de igual modo, restou demonstrada.

O policial militar Felipe narrou que: prestava patrulhamento na vicinal que liga a cidade de Panorama à cidade de Ouro Verde, na companhia da P.M. Maysa; que a referida vicinal é conhecida como meio facilitador para o tráfico de drogas, tendo em vista o fácil acesso às cidades de Ouro Verde e Dracena, e a inexistência de pedágio no trajeto; durante o patrulhamento, avistaram o veículo conduzido por Rafael, tendo Grazielly como passageira; afirma que Rafael é conhecido do meio policial pelo envolvimento na traficância; no momento em que a viatura policial foi percebida, Rafael freou bruscamente o veículo que conduzia, o que chamou a atenção dos policiais; procederam a abordagem, sendo que nada de ilícito foi encontrado no veículo, nem na posse dos acusados; efetuada a abordagem individual, Grazielly disse que estavam indo ajudar um conhecido; o réu Rafael, por sua vez, disse que estavam à procura de uma pessoa; diante das controvérsias, indagaram novamente Grazielly, que confessou ter acompanhado Rafael em uma viagem até a cidade de Ouro Verde para procurar um comprador de drogas, e que tinha ciência da existência dos entorpecentes; a partir do que foi dito pela ré, Rafael foi novamente indagado e, corroborando a versão de Grazielly, confessou ter ido até a cidade de Ouro Verde para encontrar um comprador de entorpecentes, sendo que o comprador não foi encontrado, e que Grazielly tinha ciência da existência dos entorpecentes e do intento comercial, apenas não sabia onde estavam homiziados; Rafael disse que as drogas estavam escondidas em um canavial localizado na vicinal, sentido à cidade de Panorama, próximo ao local de abordagem; Rafael conduziu os policiais até o local de esconderijo dos entorpecentes, sendo encontradas as substâncias na forma de tablete, dentro de um saco preto, sobre o solo; que, apesar de estar em um canavial, o local era de fácil acesso e os entorpecentes foram rapidamente encontrados; exarada voz de prisão, deslocaram-se até a residência de Rafael, onde, após autorizada a entrada, foi localizada, com auxílio do cão farejador, uma porção de maconha em uma cômoda no quarto de Rafael; questionado, Rafael confessou que a droga era de sua propriedade, destinada à venda; foram informados pelo indivíduo que os recebeu na residência de que Rafael residia ali na companhia de Grazielly; Rafael informou que os entorpecentes encontrados no canavial seriam comercializados pela quantia de R\$12.000,00 (doze mil reais).

Destaco que a palavra dos policiais militares é prova eficaz para a condenação nos crimes de tráfico quando corroborada pelos demais elementos probatórios (o que é o caso dos autos) e, assim tem exposto a doutrina e a jurisprudência:

O tráfico de drogas é crime comumente cometido na clandestinidade. (...) Por conta desse fato, têm como testemunhas, em regra, policiais, cuja palavra merece crédito como a de qualquer outra pessoa. Assim, caberá à defesa o ônus de demonstrar a falta de credibilidade do depoimento de policiais que, até prova em contrário, possui presunção de veracidade e potencial para um édito condenatório.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que: "O depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na

condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 278650/RS, 6ª Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/06/2016). (Mariano da Silva, César Dário. Lei de Drogas Comentada, 2ª edição, 2016, editora: A.P.M.P. pg. 85) Corroborando a jurisprudência, trago à colação trecho da ementa de precedente do C. STJ in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE IMERSÃO VERTICAL NA MOLDURA FÁTICA E PROBATÓRIA DELINEADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM NA VIA PROCESSUAL ELEITA. (...) HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. - A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...) - Habeas corpus não conhecido. (HC 477.171/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (grifei).

Interrogado, o réu Rafael negou os fatos: disse que os entorpecentes encontrados no canalial não eram de sua propriedade, e que sequer havia os indicado aos policiais; que estava se deslocando à cidade de Ouro Verde à procura de emprego; que é amasiado com Grazielly; que, durante o trajeto a Ouro Verde, foram abordados pelos policiais próximo ao canalial; que os policiais mencionaram o conhecimento prévio do envolvimento do réu na traficância e surgiram com o saco preto onde estavam os entorpecentes; alega ser usuário e que as substâncias encontradas em sua residência eram para consumo próprio.

A ré Grazielly, interrogada, negou os fatos. Disse que não tinha ciência da existência e propriedade dos entorpecentes; que não mencionou a existência de entorpecentes e traficância aos policiais durante a abordagem; que não visualizou o encontro dos entorpecentes no canalial; que é amásia de Rafael e tem a ciência de que ele é usuário; que as substâncias encontradas na residência eram para o consumo de Rafael; que não é usuária de drogas; estava na cidade à procura de emprego quando conheceu Rafael, e não tem ciência do envolvimento dele em tráfico de drogas.

Pois bem. A versão apresentada pelos réus resta isolada diante das provas coligidas nos autos.

A versão do policial militar é firme no sentido de que os acusados foram abordados pela fundada suspeita e, durante a abordagem, confessaram a prática delitiva, indicando, inclusive, o motivo da viagem, o local onde estariam homiziados os entorpecentes, e a quantia em dinheiro a ser recebida pela venda das substâncias. Os laudos periciais, atestando a presença de maconha (tetrahidrocannabinol), a forma de acondicionamento (em tabletes), a grande quantidade, a apreensão do objeto rolo de plástico filme (conforme auto de exibição e apreensão, fls.26/27- que evidentemente seria utilizado como embalagem dos entorpecentes), também afastam qualquer dúvida acerca da conduta típica do crime de tráfico.

Em que pese tenham os réus alegado que as substâncias se destinavam ao consumo próprio de um deles, as circunstâncias da abordagem, apreensão e da conduta dos acusados, como acima narrado, não se amoldam ao tipo descrito no artigo 28, da Lei de drogas.

Segue o entendimento do Colendo STJ:

(...) Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja

usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde: ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas. (STJ - REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06.03.2018).

E mais:

A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente preponderando a última, de maior gravidade (TJSP HC 42.229-3. Rel: Onei Raphael) Com efeito, I) a quantidade de entorpecentes é exacerbada e não se amolda à conduta de mero usuário (pouco mais de 8 quilos de substância, conforme auto de exibição e apreensão); II) a forma de acondicionamento (tabletes) e o fato de estarem homiziadas também não se enquadram ao uso; III) os acusados, durante a abordagem, confessaram a traficância, indicando o local onde guardaram os entorpecentes e a quantia em dinheiro a ser atribuída ao montante e recebida pela venda.

Ademais, não é necessário para a condenação que os réus sejam surpreendidos em atitude típica de transação comercial ilegal de drogas para se ter como tipificada a conduta descrita no tipo penal, pois o ato de guardar os entorpecentes com a finalidade de venda a terceiros, bem como o ato de ter em depósito para a entrega a terceiros, como nitidamente era o que os acusados faziam, já caracteriza o crime em questão, pois basta que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal. Assim, resta afastada a alegação e pleito defensivo de desclassificação para uso, uma vez que Grazielly confessou a pretensa venda dos entorpecentes encontrados no canavial e, Rafael, além de ter corroborado a versão da ré, acrescentou que os entorpecentes encontrados na residência do casal também se destinavam a comercialização, sendo incontestes a prática do tráfico por ambos, em concurso de agentes.

Friso, nesse aspecto, o julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação– Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de um tijolo de maconha no veículo do acusado– Consistentes depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem ao réu– Negativa do acusado inverossímil e isolada no contexto probatório– Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente pertencia ao acusado e era destinado ao consumo de terceiros–Condenação mantida– (...) Recurso de apelação desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500410-38.2020.8.26.0598; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/11/2021; Data de Registro: 18/11/2021) (grifei)

Ressalto que, como exposto na denúncia, ao considerar a aplicação do artigo 29, do Código Penal, denota-se presente condutas que contribuíram para o resultado do delito, mas foram menores em comparação às demais condutas, quando há coautoria. No caso, verifico uma menor participação da ré Grazielly, que, conforme a prova oral colhida, apesar de ter a ciência da existência dos entorpecentes, não tinha conhecimento do local onde estavam escondidos, no primeiro momento, nem mesmo de sua quantidade ou valores que receberiam pela venda, informações que foram detalhadas pelo réu Rafael durante a abordagem policial, revelando que o réu é quem tinha todo o controle sobre os fatos, e Grazielly, por sua vez, auxiliou com menor participação.

Assim, considerando as condutas dos réus, as penas, durante a dosimetria, serão atribuídas conforme a contribuição de cada um para o resultado do delito.

De mais a mais, inexistem causas de excludentes de antijuricidade (art. 23 do CP) ou culpabilidade (arts. 26 a 28 do CP). Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento dos réus, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime. Impõe-se, portanto, a condenação dos acusados pela prática do delito tipificado no

artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, cumulado com o artigo 29, do Código Penal. Ambos os réus são primários, conforme certidões de fl. 59 (relacionada à Grazielly) e fls. 61/62 (relacionada ao Rafael).

Passo à dosimetria da pena.

Quanto à ré GRAZIELLY

Na primeira fase, atento ao comando do art. 42 da Lei 11.343 de 2006, inicialmente analiso as circunstâncias judiciais preponderantes: a quantidade da substância, conforme auto de exibição/apreensão, é elevada, na medida que foi apreendida a quantia total de 8,222 kgs de maconha; a personalidade não prejudica, ante a inexistência de elementos para aferi-la, assim como a conduta, a natureza da substância também não prejudica. Quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, têm-se que as circunstâncias são inerentes ao tipo penal. Diante deste panorama, elevo a pena mínima do delito em 1/8, fixando a pena base em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, e 562 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena se mantém no patamar acima fixado.

Na terceira fase de aplicação da pena, constato que incide a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343 de 2006, uma vez que a acusada é primária, possuidora de bons antecedentes e que não há qualquer prova no sentido de que seja dedicada a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa, e que não incide qualquer causa geral ou especial de aumento de pena, de modo que, ante a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias específicas decorrentes da conduta da acusada, denotando sua menor participação no delito, faço incidir a diminuição de 1/2 (um meio), razão pela qual fixo a pena definitiva de 02 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão, e 281 dias-multa.

Fixo o dia multa no valor mínimo, ante a ausência de maior conhecimento das condições econômicas da ré.

A acusada ostenta a condição de primária e considerando a qualidade de pena privativa de liberdade aplicada, com espeque no que dispõe o art. 33, §2º, "c", do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade quando reconhecida a forma privilegiada do tráfico, com espeque na decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC 643.390/SC. In verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA IMPOSTA PARA UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. TIPO PENAL AO QUAL É COMINADA PENA DE MULTA CUMULATIVA COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRIORIDADE À SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ANALOGIA À SÚMULA 171/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Hipótese na qual a instância ordinária, de forma motivada, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a natureza e a variedade das drogas apreendidas (89 micropontos de LSD e 30 comprimidos de ecstasy), exclusivamente, na terceira etapa da dosimetria da pena, para fazer incidir a minorante em 1/2, o que não se mostra desproporcional. Precedentes STJ e STF. 3. O art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, nas condenações superiores a 1 ano, por duas restritivas de direitos ou por uma restritiva de direitos e multa, cabendo ao Magistrado processante, de forma motivada, eleger qual medida é mais adequada ao caso concreto. Salvo se evidenciada manifesta desproporcionalidade, deve ser mantida a pena restritiva de direitos imposta ao réu. 4. O preceito secundário do crime pelo qual o paciente foi condenado (art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006) já estabelece a cumulação da pena de multa com a pena privativa de liberdade, de modo que se deve privilegiar na substituição a escolha da pena restritiva de direito, em observância à Súmula 171/STJ. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 643.390/SC,

Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021) (grifei)

Assim, atento ao fato de que a quantidade da pena privativa de liberdade imposta é superior a um ano, substituo-a por duas penas restritivas de direitos (art. 44, §2º, segunda parte), consistentes em: prestação de serviços à comunidade à razão de 8 horas semanais pelo tempo da condenação, em favor de instituição a ser designada pelo Juízo das Execuções, e prestação pecuniária no valor equivalente a dois salários-mínimos vigentes na data desta sentença. Mantida a pena de multa.

Quanto ao réu RAFAEL

Na primeira fase, atento ao comando do art. 42 da Lei 11.343 de 2006, inicialmente analiso as circunstâncias judiciais preponderantes: a quantidade da substância, conforme auto de exibição/apreensão, é elevada, na medida que foi apreendida a quantia total de 8,222 kgs de maconha; a personalidade não prejudica, ante a inexistência de elementos para aferi-la, assim como a conduta, a natureza da substância também não prejudica. Quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, têm-se que as circunstâncias são inerentes ao tipo penal. Diante deste panorama, elevo a pena mínima do delito em 1/8, fixando a pena base em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, e 562 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena se mantém no patamar acima fixado.

Na terceira fase de aplicação da pena, constato que incide a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343 de 2006, uma vez que o acusado é primário, possuidor de bons antecedentes e que não há qualquer prova no sentido de que seja dedicado a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa, e que não incide qualquer causa geral ou especial de aumento de pena, de modo que, ante a quantidade de droga apreendida, faço incidir a diminuição de 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo a pena definitiva de 04 anos, 08 meses e 07 dias de reclusão, e 468 dias-multa.

Fixo o dia multa no valor mínimo, ante a ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

A quantidade de pena aplicada suplantou o patamar de quatro anos, assim, em obediência ao regramento estabelecido pelo art. 33, § 2º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Nos mesmos termos, incabível ao caso substituição ou sursis.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para: ABSOLVER a acusada GRAZIELLY APARECIDA PEREIRA CARDOSO do crime descrito no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, por insuficiência probatória para condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, CONDENÁ-LA à pena de 02 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 281 dias-multa, como incurso no crime descrito pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, substituída a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação e prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos vigentes na data desta sentença; e ABSOLVER o acusado RAFAEL DE SOUZA RODRIGUES do crime descrito no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, por insuficiência probatória para condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, CONDENÁ-LO à pena de 04 anos, 08 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 468 dias-multa, como incurso no crime descrito pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

A ré Grazielly Aparecida encontra-se presa por força de preventiva decretada nestes autos, desde a data em que ocorrera o crime, contudo, considerando a quantidade de pena aplicada, bem como a substituição por restritivas de direito promovida, a revogação da custódia cautelar é medida que se impõe. Assim sendo, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DA ACUSADA e concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se o competente alvará.

O réu Rafael de Souza, por sua vez, encontra-se preso preventivamente desde a data em que ocorrera o crime, não tendo a instrução processual revelado nada no sentido da modificação do quadro fático em que se apoiou a decretação da prisão provisória. Não há a mínima informação que desempenhe alguma atividade lícita, restando revigorados os requisitos da prisão preventiva, notadamente a necessidade de

custodiá-lo para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...)9. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 139.926/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) (grifei)

Assim sendo, NEGOU AO ACUSADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Recomende-se. Interposto recurso pela defesa ou acusação, expeça-se Guia de Recolhimento provisória, a fim de que sejam analisadas as possibilidades da concessão de eventuais benefícios ao acusado pelo Juízo das Execuções Penais, observando-se o que dispõe o art. 470 das Normas de Serviço.

Custas pelos réus, com exequibilidade suspensa em razão da gratuidade ora concedida.

Autorizo a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, conforme disciplina do art. 72 da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, providencie a serventia a (o):

- 1) Caso exista pena de multa, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, e, após, intime-se os acusados para comprovar nos autos o respectivo pagamento, no prazo de 10 dias, sob pena de encaminhamento de certidão da sentença ao Ministério Público, providência esta que deve ser adotada também na hipótese em que for infrutífera a tentativa de intimação (art. 50 do CP e art. 479 e seguinte das NSCGJ);
- 2) anotação da condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial (art. 372 das NSCGJ);
- 3) expedição de ofício ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ);
- 4) expedição de ofício ao TRE, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal (art. 398, II, das NSCGJ);
- 5) expedição da guia definitiva.

Cumpridas as determinações acima e realizados todos os demais atos de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.

P.I.C.

Panorama, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA